

1501281-92.2022.8.26.0438

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

1ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501281-92.2022.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501281-92.2022.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Handerson Abner Padoan Lemes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra HANDERSON ABNER PADOAN LEMES, devidamente qualificado(a) nos autos, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. Narra a inicial acusatória que, no dia 20 de junho de 2022, por volta das 15h10, na Rua Euclides Garcia do Nascimento, Bairro Eldorado, nesta cidade e Comarca de Penápolis, HANDERSON ABNER PADOAN LEMES, R.G. n. 59130759, ouvido e qualificado, respectivamente, às fls. 04 e 14/17, nas imediações de estabelecimento de ensino, trazia consigo, para consumo de terceiro, 33 (trinta e três) porções da substância Benzoilmetilecgonina, também conhecida popularmente como cocaína, na forma de "Crack", pesando 6,88 gramas (conforme laudo de constatação de fls. 11/13), o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 68/71).

O(a) réu(ré) foi devidamente notificado(a), apresentando resposta escrita às fls. 84/86.

Denúncia recebida em 02 de agosto de 2022, conforme decisão de fls. 91/92.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada

audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram inquiridas 2 testemunhas arroladas pela acusação, sendo, em seguida, interrogado o acusado (fl. 120). O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu aditamento à denúncia contra o acusado, com fundamento no artigo 384 do CPP, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 33, §1º, inciso I, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 (fls. 122/125).

Resposta escrita às fls. 141/144.

Aditamento da denúncia recebido em 05 de outubro de 2022, conforme decisão de fl. 145.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para novo interrogatório do acusado. Após, o(a) representante do Ministério Público e o(a) defensor(a) apresentaram alegações finais orais.

Os autos me vieram conclusos para sentença.

Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Antes de proceder à análise do mérito, verifico que a defesa arguiu a preliminar de inépcia do aditamento da denúncia, devendo a inicial ser rejeitada ou o réu ser absolvido sumariamente.

Não há como acolher o pleito defensivo.

Ao contrário do alegado pelo(a) defensor(a), a inicial acusatória narrou de forma escoreita o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, contendo, ainda, a qualificação do réu, a classificação do crime e o rol de testemunhas, possibilitando, assim, ao denunciado exercer a ampla defesa.

Há tão somente erro material no aditamento da denúncia relativamente à capitulação feita pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (o delito praticado pelo réu encontra-se previsto no § 1º, e não no § 3º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006), insuficiente, porém, para impossibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, não há que se falar em rejeição da exordial.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve parcial êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, “Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)” (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No caso do delito de tráfico de drogas, são indícios suficientes para a condenação do(a) agente, dentre outros: a) a confissão da prática do crime; b) a apreensão de substância entorpecente em poder do(a) autor(a) do fato e/ou de dinheiro em espécie (normalmente fracionado em notas miúdas, não possuindo o(a) denunciado(a) explicação convincente para a origem do numerário), bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes; e) a circunstância de o(a) acusado(a) ser conhecido no meio policial como traficante de drogas, responder a inquérito, já ter sido ou estar sendo processado, e/ou possuir condenação pela prática do referido delito. Em tais casos, ainda que o(a) autor(a) do fato não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, esses indícios (prova indireta) permitem que o magistrado conclua, em processo indutivo, ser ele(ela) traficante de drogas.

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo laudo de constatação (fls. 11/13), pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 108/110 e 111/112) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Conforme narrado na denúncia, no dia 20 de junho de 2022, por volta das 15h10, na Rua Euclides Garcia do Nascimento, Bairro Eldorado, nesta cidade e Comarca de Penápolis, HANDERSON ABNER PADOAN LEMES trazia consigo, para consumo de terceiro, 33 (trinta e três) porções da substância Benzoilmetilecgonina, também conhecida popularmente como cocaína, na forma de "Crack", pesando 6,88 gramas, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, no dia dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram o denunciado parado, com uma das mãos dentro do bolso da blusa de frio, no cruzamento das Ruas Euclides Garcia do Nascimento e Luiz Ambrósio. Ao verificar a presença dos policiais, o increpado começou a caminhar na tentativa de despistar os PM's.

Assim, diante de tal situação, os agentes públicos resolveram abordá-lo e, de imediato, o reconheceram de outra abordagem por drogas, bem como de informações acerca de seu envolvimento em crimes patrimoniais.

Realizada revista pessoal, foi possível encontrar, no bolso de sua blusa, um embrulho plástico contendo 33 (trinta e três) porções de crack envoltas em papel. Indagado, o denunciado disse que há quatro dias furtou uma bicicleta na companhia de Matheus Leoni e a trocou pelas porções de crack, as quais estava vendendo por R\$ 10,00 (dez reais) cada uma.

As substâncias apreendidas foram periciadas, sendo constatada a presença da substância Benzoilmetilecgonina, também conhecida popularmente como cocaína conforme laudo de, constatação de fls. 11/13. Assim, a natureza, quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos evidenciam que HANDERSON trazia as porções de crack para posterior entrega ao consumo de terceiros.

Posteriormente, o MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou aditamento à denúncia, com fundamento no artigo 384 do CPP. Sustentou o Parquet que, de acordo com o laudo toxicológico definitivo encartado aos autos poucos dias antes da audiência de instrução, a substância que o réu trazia não era cocaína (apontada pelo laudo de constatação a fls. 11/13), mas lidocaína (laudo definitivo a fls. 108/110 e 111/112).

E a lidocaína, apesar de não integrar a lista de substâncias entorpecentes, consta da lista III da Portaria MJ 240/2019" (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), como produto químico capaz de ser empregado na preparação de drogas e sujeita a controle e fiscalização a partir de um grama, em qualquer concentração.

Por conseguinte, o crime em tese praticado pelo réu não é o do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06, conforme a denúncia, mas o do inciso I do § 1º do mesmo dispositivo legal (trazer consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas).

Vejam os.

O acusado HANDERSON ABNER PADOAN LEMES, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que "reserva o direito de manifestar somente em Juízo." (fl. 04). Na primeira audiência de instrução e julgamento, o(a) denunciado(a) HANDERSON ABNER PADOAN LEMES sustentou que tem 19 anos e é dependente químico, tendo feito tratamento para dependência química. Disse que, na data dos fatos, estava usando crack na casa de sua irmã, e ao sair da casa dela, furtou uma bicicleta para trocar em algumas porções de crack com "Gabriel", cujo nome completo não se recorda. Gabriel mora no bairro de Silva Covas. Afirmou que, na hora da abordagem, os policiais bateram em seu rosto. Disse que cada porção de droga valia R\$ 10,00. Declarou que as drogas não eram pra revender e sim para o seu próprio. Na segunda audiência de instrução e julgamento, o(a) denunciado(a) HANDERSON ABNER PADOAN LEMES sustentou que é usuário de drogas. O entorpecente que trazia consigo se tratava de crack e era destinado ao seu uso. Não sabe o que é lidocaína. Trazia consigo pequena quantidade de droga. Já foi internado anteriormente em uma clínica de Tupã para tratamento de seu vício.

A testemunha IGOR JOSÉ DE OLIVEIRA, policial militar, em solo policial, disse que "estava em patrulhamento pelo bairro Eldorado e passando pela Rua Euclides Garcia do Nascimento, mais precisamente no cruzamento com a Rua Luiz Ambrósio, deparou com o indiciado aqui presente parado na esquina, com a mão no bolso da blusa de frio; ao aproximar, o indiciado passou a caminhar, para deixar o local, quando fez a abordagem, neste momento o reconheceu, pois já o surpreendeu com drogas e tinha informação que comercializava e praticava furtos; estava com seu colega Prado e em revista pessoal, encontrou no bolso da blusa, um embrulho plástico e no interior, trinta e três porções de substância amarelada, envolta em alumínio, que não tiveram dúvidas ser cocaína na forma de crack; indagado a respeito, o indiciado disse que furtou uma bicicleta de cor roxa, modelo Ceci, na companhia de Matheus Leoni, cerca de quatro dias e trocou por aquela droga no local conhecido como "baia", com um desconhecido e estava vendendo a dez reais cada porção; deu-lhe voz de prisão e o conduziu a esta unidade; deseja esclarecer que o local da abordagem fica menos de cem metros de uma escola municipal e uma creche, as quais estavam em funcionamento; deu ciência ao pai do indiciado a respeito de sua prisão e este informou que não acompanharia porque o filho é reincidente e está dando trabalho para a família" (sic) (fl. 02). No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar BRUNO PRADO DE OLIVEIRA (fl. 03).

Ao ser inquirida na audiência de instrução e julgamento, a testemunha IGOR JOSÉ DE OLIVEIRA sustentou que estava em patrulhamento juntamente com o policial militar Bruno, quando passou por um ponto de venda de droga, oportunidade em que avistaram o acusado com uma blusa de frio e com as mãos no bolso, encostado na parede. O réu ao atentar para a aproximação dos policiais, deixou o local, porém os depoentes o alcançaram e realizaram abordagem e revista pessoal, encontrando com ele 33 porções envoltas em um saco plástico contendo um pó amarelo, que constituía "crack". O acusado afirmou para as autoridades policiais que a droga era proveniente do furto de uma bicicleta, que havia sido trocada por drogas para revender pela quantia de R\$10,00 cada porção. O acusado estava a proximamente 100 metros de uma creche municipal.

Ao ser inquirida na audiência de instrução e julgamento, a testemunha BRUNO PRADO DE OLIVEIRA sustentou que estava em patrulhamento juntamente com seu colega de trabalho, oportunidade em que avistaram o acusado em local que é conhecido como "biqueira", isto é, ponto comercialização de drogas. Ao se aproximar de Handerson, que estava encostado no muro a uma distância de 70 metros de uma escola municipal, o réu tentou sair do local colocando a mão nos bolsos da blusa. O depoente já conhecia o acusado por ter apreendido ele em outras abordagens policiais anteriores por tráfico de drogas. Contudo, ao fazer a revista pessoal do réu, verificaram que ele trazia consigo 33 porções de crack, envolvidas em um papel alumínio. O réu disse que estava vendendo cada porção por R\$ 10,00, contudo a compra da droga para revender era proveito de furto de uma bicicleta. Como o acusado estava sem

documento de identificação, o conduziram até sua residência e conversaram com o genitor do réu sobre o ocorrido. O genitor informou que já está cansado do envolvimento de seu filho com o comércio de drogas. Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Além disso, é fato notório e de conhecimento geral que, nos crimes (e atos infracionais) de tráfico de drogas, impera a lei do silêncio, haja vista que a(s) testemunha(s) do fato, sentindo-se amedrontada(s) e temendo por sua integridade física e/ou de seus amigos e familiares, optam por se calar, por fornecer pouco(s) detalhe(s) a respeito da empreitada criminosa ou, simplesmente, por mentir à autoridade policial e/ou ao(à) magistrado(a). Em tal contexto, a(s) denúncia(s) anônima(s) e o(s) depoimento(s) de policiais civis e militares possuem grande valor probatório.

5. A defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da inimputabilidade do(a) acusado(a) e sua absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança de internação ou de tratamento ambulatorial.

Não há como ser acolhido tal pleito.

In casu, não há qualquer indício de que o réu, ao tempo dos fatos, fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se comportar segundo tal entendimento, não sendo suficiente a alegação de que, na data dos fatos, teria feito uso de substâncias entorpecentes ou de álcool.

Nos termos do caput, do artigo 45, da Lei n.º 11.343/2006, "É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento" (grifo meu).

Referido dispositivo legal deve ser interpretado conjuntamente com os artigos 26, 27 e 28 do Código Penal, que igualmente tratam da inimputabilidade como causa de exclusão da culpabilidade. Como bem destaca Guilherme Nucci, "o art. 45 é desnecessário, diante dos arts. 26, 27 e 28 do Código Penal. Quem é viciado em qualquer substância entorpecente (incluindo-se, nesse contexto, o álcool), para o atual conceito médico, é doente mental. Portanto, o disposto no art. 26 seria suficiente tanto para quem padece de uma enfermidade mental, como, por exemplo, a esquizofrenia, como também para aqueles que são dependentes de drogas em geral" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 451 - grifo meu).

Pois bem. A teor do § 1º, do artigo 28, do Código Penal, apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, é capaz de excluir a imputabilidade, desde que, em razão da ingestão de álcool ou de substância de efeitos análogos (e, acrescentamos, do uso de drogas e outras substâncias entorpecentes), o agente seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O caso dos autos, no entanto, amoldar-se-ia, em tese, à hipótese contemplada no inciso II, do caput, do artigo 28, do Estatuto Repressivo, segundo o qual a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool, drogas ou outra substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria: TJMG - Apelação Criminal n.º 1.0672.14.020730-5/001, 7ª Câmara, Relator(a): Agostinho Gomes de Azevedo, 11/06/2015; TJRS - Apelação Criminal n.º 700581169478, 2ª Câmara, Relator(a): José Ricardo Coutinho Silva, 21/05/2015.

Além disso, não requereu a defesa, no momento processual oportuno, a instauração do incidente de insanidade previsto no artigo 149 do CPP, estando precluso seu direito de produzir prova pericial para comprovar tal alegação.

Por fim, e não menos importante, "a implementação do incidente não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado" (STJ - HC 375.266/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado

em 07/02/2017, DJe 14/02/2017), o que, a meu sentir, não é o caso dos autos, conforme acima demonstrado.

6. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do(a) acusado(a).

7. A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do § 2º, do artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Tóxicos não exige que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia para que sua conduta seja enquadrada no tipo penal do artigo 33, caput. Isso porque o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas").

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, "para alicerçar a pretendida condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (TJSP; Apelação Criminal 1500705-48.2018.8.26.0274; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019 - grifo meu).

Ademais, a condição de usuário ou dependente de drogas não é incompatível com a figura do traficante, tampouco afasta per si a imputabilidade do agente. Nesse sentido: TJMS, HC 01733320620158110000, Relator: Desembargador Gilberto Giraldelelli, DJ 04/02/2016; TJDF, APR 0015443-41.2008.807.0001, Relator: Desembargador Souza e Ávila, DJ 03/02/2010.

In casu, não foi apreendida cocaína, na forma de crack, mas sim lidocaína, substância destinada à preparação de drogas e sujeita a controle e fiscalização a partir de um grama, em qualquer concentração, nos termos da lista III, da Portaria MJ n.º 240/2019 (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

Ainda que a substância entorpecente apreendida fosse cocaína, a quantidade apreendida (6.88 gramas) e sua forma de acondicionamento (em diversas porções, que facilitam o transporte e comercialização) revelam a intenção do(a) denunciado(a) de praticar a traficância ilícita.

Com efeito, conforme se extrai de julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo: a) um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5g a 1,0g do entorpecente; b) uma "fileira" de cocaína é confeccionada com 0,1g a 0,125g da droga, aproximadamente; c) uma pedra de crack tem, em média, 0,2g a 0,25g.

Confira-se: Apelação Criminal 1500949-81.2019.8.26.0228; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019; Apelação Criminal 0000617-39.2016.8.26.0247; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018; Apelação Criminal 0000244-

11.2015.8.26.0613; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016.

8. A defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.

O pleito defensivo deve ser acolhido.

Com efeito, como bem destacado pela combativa defesa às fls. 141/144, em especial o mapa de fl. 142, o local dos fatos não está situado próximo aos estabelecimentos de ensino "Escola Municipal Maria da Graça Gonçalves Silva" e "Escola Luzia Maria Bernardes Nory".

Inexistindo evidências de que o delito tenha sido perpetrado nas imediações dos estabelecimentos de ensino supra mencionados, de rigor o decote da causa de aumento de pena do inciso III, do artigo 40, da Lei n.º 11.343/2006.

9. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

In casu, embora primário e portador de bons antecedentes o acusado se dedica à prática de atividades criminosas, porquanto responde a outro(s) processo(s) criminal(is), com denúncia oferecida e recebida, pela prática de delito(s) praticado(s) antes daquele que é objeto da presente ação penal: processos n.º 1500707-69.2022.8.26.0438 e 1500639-22.2022.8.26.0438.

Conforme já decidiu a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06" (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017 - grifo meu).

II.3 - Da dosimetria das penas

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

No caso dos autos, nenhuma das 8 (oito) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime,

circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima) pode ser valorada negativamente.
Estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Reconheço a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, atentando para o disposto no enunciado da Súmula n.º 231 do STJ.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. “Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 – grifo meu).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, com fundamento nos artigos 33, §§ 2º, “b”, e 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo,

mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o acusado já foi contemplado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, prevalece no STF e no STJ o entendimento de que o sursis é inaplicável aos crimes hediondos ou equiparados, pois a dimensão do benefício não se coaduna com a natureza do delito, em relação ao qual a própria CF, em seu artigo 5º, XLIII, determinou tratamento mais severo (STF, HC 101.919/MG; STJ, HC 197.268/SP).

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o(a) acusado(a) HANDERSON ABNER PADOAN LEMES como incurso(a) nas sanções do artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do(a) acusado(a) e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, que continua necessária para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: "HABEAS CORPUS - Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal - [...] Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência - Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada [...]". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2262474-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020 - grifo meu).

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final. Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir prejuízo material constatado.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88;

Porque não interessa a preservação das drogas apreendidas, oficie-se, determinando a incineração delas, mediante termo circunstanciado.

Demonstrado que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, decreto seu perdimento em favor da União Federal, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei

11.343/2006.

Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Penápolis, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA